

刑法
No.394

予備独自問題 R 5-8

(配点: 2)

月 日

月 日

賭博の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。
2. あるスポーツの勝敗に関し、あらかじめ勝敗の結果を知った上、その結果を知らない者との間で金銭を賭けて利益を得た場合、当事者全員に賭博罪が成立する。
3. 一般多数人をして、スポーツの勝敗に関し、賭博をさせて利益を得るため、賭博の主催者が、参加者を特定の場所に集めることなく、事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。
4. それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をしたとしても、数日間営業を行ったにすぎない場合には、甲に常習賭博罪が成立することはない。
5. 賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幫助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幫助犯が成立する。

(参照条文) 刑法 (改)

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。

- 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3年以上5年以下の拘禁刑に処する。

No394	賭博罪		正答率
予備R5-8	正解	3	65%

1 誤っている

大判大 6.11.8 は、賭博罪が成立するためには、勝敗の結果として財産上の利益の得喪が実現したこと又は勝敗が決したことを必要としないとしている。その理由として、学説は、賭博罪は挙動犯であり、実行の着手と同時に既遂となるということを挙げている。

2 誤っている

最判昭 26.5.8 は、賭博行為に参加した者のうち、勝敗の結果について偶然性がない者が存在した場合、欺罔手段を用いた側には詐欺罪のみの成立を認め、相手側には賭博罪は成立しないとしている。

3 正しい

賭博場の「開張」とは、賭博場の設営に当たって主宰の地位に立つことをいうが、必ずしも賭客の誘引ないし招集の行為を伴う必要はない(大判大 12.2.28)。最決昭 48.2.28 は、いわゆる野球賭博を行わせて利益を得るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備え付け、同所において、電話により賭客の申し込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申し込みを集計して整理し、また、当該プロ野球の試合の結果に基づいて勝者に支払うべき賭金及びその中から徴収すべき寺銭の集計などをし、さらに寺銭を徴収するなどの方法により野球賭博を開催した事案について、賭博場開張図利罪(186条2項)が成立するとしている。

4 誤っている

常習賭博罪の常習性の判定に当たっては、遊技場の種類、設置場所、台数、営業時間、投下された資金の額等によって常習性が判定される。最決昭 54.10.26 は、長期間営業を継続する意思の下に、多額の資金を投下して多数のゲーム機を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの3日間、営業を継続した事案において、常習賭博罪が成立するとしている。この判例は、投下資金に拘束され賭博営業をやめることができないという「資本的もしくは経済活動上の依存性」(原判決参照)によって本罪の常習性を肯定したものとされている。

5 誤っている

大判大 2.3.18 は、常習性のない者が賭博常習者同士の賭博を幫助した事案において、常習性のない者には単純賭博罪の幫助犯が成立するととどまるとしている。その理由として、判例は、①65条1項は、犯人の身分をもって構成要件とする犯罪に加功した者は身分なき者といえども共犯として処分することを規定したものである、②賭博罪は、犯人に賭博の常習があるか否かは犯罪の成否に影響はなく、常習があるか否かに従い罰条が異なるのは犯罪の構成要件が異なるためではなく、法律がこれを処罰するに当たり軽重相異なる別個の刑をもってした結果に外ならない、したがって、常習者の賭博行為に常習性のない者が幫助した場合は、65条1項が適用される場面ではないということを挙げている。